



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 23/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

- התובעים:
1. נציגות הבית המשותף רחוב מרחביה 14 תל אביב
 2. דן ללוז
 3. אמנון קשי
 4. הינדה ווייס
- ע"י ב"כ עוה"ד צבי קורץ
מרחוב קפלן 2, בית יכין, תל אביב

נגד

הנתבע:

משה אלגזי
ע"י ב"כ עוה"ד מאור בן דוד
מרחוב טשרניחובסקי 16 כפר סבא

פסק דין

תובענה זו עניינה בבית ברחוב מרחביה 14 תל אביב הבנוי על חלקה 34 בגוש 8986 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

התובעת 1 הינה נציגות הבית.
התובעים 2 עד 4 הינם בעלים של 5 דירות בבית (תתי חלקות 8 עד 12).
הנתבע הינו בעלים של שתי יחידות בבית (תתי חלקות 5 ו-6).

התביעה הוגשה כנגד נתבעים נוספים, בעלים של דירות אחרות בבית, אך הדיון בה פוצל בהתאם להחלטתי מיום 12.01.12.

התובעים טוענים כי הנתבע 8 פלש לחצר המהווה רכוש משותף ובנה מחסן לחנות שבבעלותו בתוך שטח החצר תוך שהוא עושה שימוש בלעדי ברכוש המשותף. לטענת התובעים יש לחייב את הנתבע להרוס כל בניה שביצע בחצר ולאפשר גישה חופשית של בעלי הדירות לחצר זו וכן יש לחייבו בתשלום דמי שימוש ראויים בסך של 26,250 ₪.

כתב התביעה כלל בקשות לסעדים נוספים כנגד הנתבע. אולם, התובעים זנחו סעדים אלו במהלך ניהול ההליכים והתמקדו בשניים האמורים לעיל - השימוש בחצר ודמי השימוש (ר' גם סעיף 5 לסיכומי התובעים).

הנתבע טוען כי בניית המחסן בוצעה לפני שנים, עוד בשנות ה-30 של המאה הקודמת, בסמוך לאחר בניית הבית. הנתבע קיבל את הזכויות בנכס בירושה במצבו כפי שהוא ומעולם לא בנה דבר. גם בצוואה על פיה רכש את הזכויות מוזכר המחסן בחצר. בנסיבות אלו נטען כי התביעה התיישנה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 23/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

או הוגשה בשיהוי ניכר. לא הובעה כל מחאה או תביעה על ידי בעלי הדירות בקשר למחסן ומשכך הנתבע שינה מצבו לרעה בהשקיעו כספים רבים במחסן והשכרתו לצד שלישי. הקמת המחסן נעשתה על פי הדין. התובעים רכשו את זכויותיהם בבית שעה שהמחסן כבר היה בנוי ואין הם יכולים לחזור בהם מהסכמות הקודמים להם בזכויות. בנסיבות אלו הנתבע זכאי לעשות שימוש במחסן, בין מכח היותו ברשות בעל רישיון מכללא ובין מכח עקרון תום הלב. לחילופין נטען כי נוצרה זיקת הנאה מכח שנים ולחילופין התביעה נוגדת את הוראות סעיף 14 לחוק המקרקעין. הנתבע מכחיש את חובתו לשלם דמי שימוש ואת גובה דמי השימוש הנתבעים. עוד נטען כי הנציגות לא הוסמכה כדין וכי היא איננה מוסמכת לנקוט בהליך דנן.

דיון

הכלל הבסיסי הוא כי נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") והוא מוטל על שכמו של התובע בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).

תשריט הבית המשותף בשילוב עם ממצאי הביקור במקום מלמדים כי המחסן חורג משטח קונטור הבית ואינו נכלל בתוך תחום סימון תתי חלקות 5 ו-6 בתשריט הבית. הממצאים מלמדים כי המחסן מצוי בשטח החצר המהווה רכוש משותף על פי מסמכי הרישום. כך עולים הדברים מחוות דעתו של השמאי הראל שלא נסתרה. כך הם עולים גם מעדויות הנתבע (ר' עמוד 9 שורות 19-20 ועמוד 11 שורות 6-1). מן העדויות שנשמעו בפני עולה כי, למעשה, אין בין הצדדים מחלוקת כי המחסן ממוקם בשטח המוגדר "חצר" בתשריט הבית המשותף, ושטח זה הינו רכוש משותף (שעה שלא הוצמד לאיזה מיחידות הבית).

די בכך מבחינת התובעים כדי לעמוד בנטל ההוכחה הנדרש, בפרט כאשר המדובר בהליך המתנהל בפני מפקח על רישום מקרקעין (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פ"ד לח (4) 487). עתה עובר נטל ההוכחה לידי הנתבע - על הנתבע הנטל להוכיח כי בידו הסכמות של בעלי הדירות לבינוי הקיים בחצר הבית והשימוש בו (ר' רע"א 296/11 מוחמד נג'אר נ' שאוקי חמדאן עליאן (פורסם בנבו)).

בטרם נבחן את הראיות שהוצגו בהליך דנן ובאם עלה בידי הנתבע להוכיח זכאותו להמשיך ולעשות שימוש במחסן הבנוי על הרכוש המשותף, נכון יהיה לסקור בקצרה את ההלכות המשפטיות הרלבנטיות.

תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, בדומה להצמדה של רכוש משותף לדירה על פי סעיף 62 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), טעונה הסכמה של בעלי הדירות. בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לדיירים האחרים ברכוש המשותף כפי שנפסק בע"א 2525/92 גבי וקרני ואוכברגר נ' עיריית רמת גן פ"ד מז(5) 850: "...משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות. תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה ב'רכוש המשותף', המיועד לשמש את כל 'בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 23/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הדירות, שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מ'הרכוש המשותף' משאר 'בעלי הדירות', ו'ברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם'... (ר' גם רע"א 698/85 בן צור נ' נעים ששון מא(3) 144; י. ויסמן דיני קניין בעלות ושיטתו (תשנ"ז, 1997) עמ' 455-454).

ברי כי שימוש בגינה לבניית המחסן והרחבת חנות הנתבע בפועל לשטח זה, לא יכול להיות, מעצם טבעו, בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כ"ח (1) 645; ע"א 708/72 פרשק נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב (1) 49 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

שימוש ייחודי של בעל דירה ברכוש המשותף, דורש אם כן הסכמה של כל יתר בעלי הדירות - ומהי אותה הסכמה נדרשת?

כבר נפסק בעבר כי הסכמת בעלי הדירות לשימוש ברכוש המשותף והקניית זכויות קניינות איננה חייבת להינתן בכתב דווקא ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה. הסכמה שכזו גם יכולה לחייב בעלי דירות אחרים שידעו על קיומה ונהגו על פי מציאות קיימת. הסכמה למתן רשות שימוש יכולה להילמד גם מכללל ומהתנהגות הצדדים לאורך שנים. אולם, בכדי ליתן תוקף קנייני להסכמה הרי שזו צריכה להיות מפורשת ולא ניתן ללמוד עליה במשתמע (ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד לו(3) 78; ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף (פורסם בנבו); ר' ע"א 9502/06 (מחוזי - י-ם) רונית לומברוזו נ' מיכאל קובנר (פורסם בנבו); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא(3) 210).

על מנת להסיק ויתור מהתנהגות הרי שזו חייבת להיות "ברורה וחד משמעית, ולהעיד על גמירות דעת, ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר" (ע"א 7388/97 עיזבון משה זמיר ז"ל נ' יעל דולב (שמיר) (פורסם בנבו)).

משעה שניתנה ההסכמה, אין להתיר לבעל דירה שהסכים להתנער מהסכמתו או לחזור בו ממנה כאשר קיימים של מניעות מטעמי צדק (פרשת כליפא לעיל וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הוברט פ"ד לז(2) 497; ע"א 31/70 כהן נ' שמאי פד"י כ(2) 388).

עתה לבחינת הראיות בהליך דנן.

לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי נתקבלו הסכמות פוזיטיביות של בעלי הדירות בבית, במועדים הרלבנטיים, לבניית המחסן בחצר הבית. בהקשר זה לא הובאה על ידי הנתבע, עליו הנטל, ולו ראיה אחת, המלמדת על קבלת הסכמה כלשהי של מי מבעלי הדירות בבית לבינוי האמור, לא הסכמה בעל פה וודאי שלא הסכמה בכתב.

ויוער, האמור נכון בין אם תתקבל גרסת הנתבע לפיה המחסן נבנה בשנות השלושים של המאה הקודמת ובין אם תתקבל גרסת התובעים, כפי שעולה מעדותו של מר ארז לוטן, לפיה רק בשנות האלפיים נבנו קירות המחסן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 23/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מעדויות הנתבע עולה כי הזכויות בכל דירות הבית היו, לאורך השנים, בידי בני משפחתו. מר יצחק אלגזי מעיד כי הבית נבנה על ידי סביו ואביו וכי כל הבית היה בבעלותם (עמוד 8 שורות 29-30). אף על פי כן, צו רישום הבית המשותף לא תוקן מעולם כך שישקף גם את המחסן שנבנה, לכאורה, עוד בשנות ה-30 של המאה הקודמת. ויודגש, תיקון צו הרישום כאמור לא בוצע גם כאשר חולקו דירות הבית בין יורשי הבעלים המקוריים באופן זה שלא היה עוד בעלים אחד משותף לכל הדירות בבית.

זאת ועוד. חלק מדירות הבית נותרו גם כיום בבעלות היורשים המקוריים. דא עקא, על אף שהמדובר בקרובי משפחה של הנתבע, על אף שהם יורשי הזכויות המקוריים, כפי שהוא רכש את זכויותיו (ראה נספח ב' לתצהירו) ועל אף שלכאורה בידם לאשר את ההסכמות שניתנו לנתבע לשימוש בחצר לאורך השנים, לא הובאה על ידי הנתבע ולו עדות אחת מבעלי הזכויות האלו לתמיכה בטענותיו. כך, מסיבותיו שלו, וללא כל הסבר, בחר הנתבע שלא להביא לעדות בפני את הגב' טמיר או את ה"ה אלגזי או את הגב' פרנס. ויודגש, המדובר בבעלי דירות זמינים שניתן היה בנקל לזמנם למתן עדות, שהרי, גם הם נתבעו בהליך המקורי (בטרם הורתי על פיצול הדיון), וכנגד חלקם עוד מתנהלים הליכים משפטיים בפני.

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פ"ד לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651).

בנסיבות דנן ניתן להסיק כי לא הנתבע ולא קודמתו בזכויות קיבלו הסכמה לבניית המחסן והשימוש בחצר וממילא גם לא רכשו כל זכויות בשטח החצר. ויוער, גם לא הוכח כי במסגרת הסכמי רכישת הזכויות בדירות בבית על ידי התובעים או קודמיהם בזכויות, הייתה התייחסות כלשהי להסכמה לשימוש הייחודי של הנתבע בחצר לטובת מחסן. הוכח דווקא היפוכם של דברים, כפי שעולה מעדותו של מר לוטן "שמכרתי את הדירה להינדה ציינתי בפנייה שיש מחסן ברכוש המשותף. ש.ת. היא אמרה שזה בעיה מבחינתה היה דיון שצריך לטפל בזה ולפרק את זה וחלק מהעניין היה לציין את העובדה הזו שזה בנוי על הרכוש המשותף" (עמוד 6 שורות 3-5).

אין גם כל הסבר מניח את הדעת מדוע לא רשמו את המחסן, אם אכן היה בנוי עוד משנות ה-30 של המאה הקודמת, כחלק מיחידות הנתבע במסמכי רישום הבית המשותף או מדוע לא הצמידו את החצר לאיזה מדירות הבית או אפילו לא נתנו זכות שימוש ייחודית תקנונית, כל זאת שעה שכל הזכויות בבית היו בידי הבעלים המקוריים ובידם היתה הזכות החוקית לבצע כל רישום ו/או תיקון במסמכי רישום הבית המשותף. הטענה כי המדובר היה בנכס שנבנה לטובת המשפחה ולא היה כל צורך ברישום אין בה להוות הסבר בהקשר זה, שהרי, מעדותו של מר יצחק אלגזי עולה כי מראש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 23/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

חילקו את הבית בין בני המשפחה (עמוד 9 שורה 4). ברי כי חלוקה שכזו חייבת היתה לקבל ביטוי כלשהו במרשם (כפי שאכן נעשה ברישום הבית המשותף ויחוד הדירות לבני משפחה ספציפיים ללא ייחוס החצר לדירה קונקרטי).

ויוודגש, הבית המשותף נרשם בשנת 1955. על פי התשריט שצורף למסמכי הרישום, לא בנוי כל מחסן בשטח המוגדר כ"חצר". תשריט זה משקף את מצבו של הבית במועד הרישום. משכך, ובהעדר כל אזכור למחסן נשוא ההליך דנן, הרי שממילא אין לקבל את טענת הנתבע כי המחסן נבנה בסמוך לאחר הקמת הבית.

גם אין במסמך העירייה שהוצג על ידי הנתבע (נספח א' לתצהירו) כדי לסייע בעדו. ראשית, אין המדובר במסמך על מחסן בחצר אלא על צריף המשמש כמטבח. בענייננו, אין כל מטבח במחסן ולא תשתית לקיומו של מטבח כזה. שנית, לא ניתן להבין מן המסמך לאיזה חצר ולאיזה צריף הכוונה. לאור המצב העובדתי בשטח סביר כי הכוונה לבניה בחלק אחר של החצר. שלישית, כאמור, בשנת 1955 הוגש תשריט אשר שיקף את מצב הבית בפועל ובו אין כל אזכור לא למחסן וגם לא לצריף או מטבח בחצר. אף אם היה צריף בחצר בשנת 1934, הרי שעד שנת 1955 זה כבר לא היה קיים ומשכך, ממילא, אין המדובר במחסן נשוא ההליך דנן.

אעיר כי גם לא עלה בידי הנתבע להוכיח במאזן ההסתברויות הנדרש כי המדובר על אותה בניה בחצר משנות ה-30 של המאה הקודמת. הנתבע בודאי שאינו יכול להעיד על כך, בפרט כאשר היה במקום לכל היותר פעם אחת, וגם זאת עשרות שנים לאחר הבניה הנטענת (עמוד 11 שורות 12-13). גם עדותו של אביו - יצחק אלגזי, לא היה בה כדי לשכנע. עדותו היתה מבולבלת כאשר הוא מערב בין זיכרונות מן העבר הרחוק (שלא ברור כלל אם בידעתי האישית) לבין זיכרונות מן העבר הקרוב (בתקופה בה ניהל עבור הנתבע את הנכסים בבעלותו) וסותר את עצמו שוב ושוב בנושאים הרלבנטיים (ר' למשל עדותו בעמוד 9 שורות 9-13). מעדותו של מר אלגזי עולה כי אכן מדובר בבניה שונה - בעדותו הוא מתייחס לבניה בחצר אשר שימשה למגורי דודתו (עמוד 9 שורות 7-8). דא עקא, המחסן נשוא הדיון אינו ראוי ואינו יכול לשמש למגורים. מר אלגזי גם אינו מצליח לזהות את מיקום הבניה בחצר (היכן שגרה דודתו) על גבי תשריט הבית המשותף (עמוד 9 שורות 17-18).

אין כל נפקות לטענת הנתבע כי התובעים רכשו את זכויותיהם שעה שהמחסן כבר היה בנוי - משלא הוכחה הסכמה של בעלי דירות, לא הקודמים ולא הנוכחיים, ממילא אין בידי הנתבע כל זכות בת תוקף לשימוש הייחודי בחצר. גם טענתו כי בניית המחסן לא נעשתה על ידו אין בה לסייע לו. הסגת גבול הינה מסוג "עוולה מתמשכת". כך, בכל יום בו המחזיק שלא כדין בנכס, ממשיך בחזקתו, קמה לבעלים עילת תביעה נוספת, המתחדשת מדי יום. הסגת גבול יוצרת עוולה הנמשכת והולכת וזו "מולידה עילת תובענה חדשה מדי יום ביומו כל עוד נמשך מצב הענינים הפוגע..." (ר' ע.א. 35/71 חב' ישראל אוסטרליה בע"מ ואח' נ' מושב בני דרור בע"מ, פד"י כ"ז (1) 225 בעמ' 228 והפסיקה המצוטטת שם). בספרות המשפטית נאמר כי "הדין רואה עקרונית 'מעשה או מחדל כ'נמשכים' וכמולידים עילות תובענה מעת לעת, באותם מקרים בהם נתון הדבר בכוחו של העושה (או החדל) להפסיק מעשהו או מחדלו ובדרך זו שלא עוד לעשות עוולה או לגרום נזק ובלבד שאותה 'המשכיות' אינה נסמכת לאחר אל מעשה חד פעמי" (טדסקי, אנגלרד, ברק וחשין: דיני הנזיקין, תורת הנזיקין הכללית, מהד' שניה תשל"ז, בעמ' 724 ה"ש 7). לפיכך, ממילא קיימת עילת תביעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 23/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בסמכות המפקח כנגד הנתבע בגין השימוש המבוצע על ידו כיום. מסיבה זו גם אין מקום, ממילא, לקבל את טענת ההתיישנות של הנתבע.

בנסיבות דנן כל שיש בידי הנתבע להוכיח הוא העדר התנגדות של בעלי דירות לשימוש בחצר לטובת המחסן לאורך שנים – מעדותו של השמאי טדי הראל עולה כי גילו של המחסן "כמה עשרות שנים" (עמוד 3 שורה 28). אף אם המחסן לא נבנה כנטען בשנות ה-30 של המאה הקודמת, האמור מעמיד בספק את עדותו של מר לוטן לפיה בשנת 1999 לא היה בנוי המחסן (למעט קירוי) וזה הותקן רק בשנת 2002 (עמוד 5 שורות 1-3). בהחלט יתכן כי מה שראה מר לוטן היה את שיפוץ המחסן לאחר שריפה שהיתה בנכס על פי עדות הנתבע (ר' עמוד 12 שורות 7-8).

מכל מקום, בין אם המחסן בנוי עשרות שנים ובין אם רק משנת 1999 או 2002, הרי שמאז ועד למועד הגשת התביעה חלף למעלה מעשור שנים, לכל הפחות, בו השלימו בעלי הדירות עם השימוש בחצר לטובת המחסן ולא נקטו כל הליכים כנגד הנתבע או דרישה כלשהי להפסקת השימוש. כך עולה מעדותו של מר לוטן - "אמרו לי שאפשר להגיש חמש שנים אחורה ועדיין לא הגשתי ב-2006 כי לא התייחסתי בכלל למחסן התייחסתי למבנה ההוא" (עמוד 5 שורות 28-29) ובהמשך "זה לא שזה לא היה בעיה בעיניי ותמיד דיברתי על זה שזה תפיסה של הרכוש המשותף זה לא דבר שלא נאמר מעולם רק שהיו בבניין הזה מספיק בעיות כמו שיפוץ חדר המדרגות שיפוץ הכניסה ידעתי שבגלל יחסי משפחת אלגזי ורחל טמיר אם היינו מתעסקים על הגג והחצר לא היינו מתקדמים בדברים אחרים. ש.ת החלטתי הייתה לא לעשות עם זה כלום כי היו דברים שידעתי אם זה דברים אחרים לא יתקדמו." (עמוד 6 שורות 14-18). כלומר, בעלי הדירות, אשר היו מודעים לשימוש ברכוש המשותף בחרו, במודע, שלא לנקוט בהליכים כנגד הנתבע ולא להביא להפסקת השימוש על ידו. כך גם עולה מעדותו של מר קשי "לא התלוננתי על המחסן כי ידעתי שהמחסן הוא לא חוקי ויבוא יום והעירייה תוריד אותו לא רציתי להלשין. ש.ת הדיירים שהיו שם אמרו לי שהחצר שלנו וזה משותף מי שמכר לי את הדירה אמר לי שזה חצר משותפת גם הייתי בעירייה שם הוצאתי את המפות ואין סימון שהמחסן שלהם. ש.ת כל זה היה בשנת 2005 מאז כבר ידעתי" (עמוד 7 שורות 18-22). במיוחד אמורים הדברים בנסיבות בהן בעלי הדירות גם ידעו על כך שהנתבע משכיר את המחסן שבחצר (עמוד 7 שורה 26).

דא עקא, אי התנגדות של שכנים לעבודות, אף אם נעשו לפני שנים, אין בה די כדי להוות הסכמה מודעת לשימוש. לכל היותר ניתן להסיק משתיקה שכזו הסכמה מכללא אשר מקימה לנתבע רשות שימוש הדירה, כזכות אישית, אשר ניתנת להפסקה בכל עת על ידי המעניק אותה, בודאי כאשר המדובר ברשות שימוש ללא תמורה - "רשות שנלמדת מכללא אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חינוס המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני" (פרופ' נ. זלצמן רשיון במקרקעין, הפרקליט מב 24, 57; וראה גם מ. דויטש, קניין כרך ב' (התשנ"ט-1999) 414).

משהוגשה התובענה דנן הביעו בברור חלק מבעלי הדירות את רצונם להפסקת השימוש על ידי הנתבע (מיגל דויטש קניין (תשנ"ט, כרך ב') עמ' 414, רע"א 6339/97 רוקר ואח' נ' סלומון ואח' פד"י נח (1) 199 וע"א (ת"א) 2816/03 ציפורה קונצ'יצקי ואח' נ. דליה שפולן ואח' תק-מח 2006 (2), (991).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 23/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויודגש, רק במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושבהם, בהסתמך על מתן הרישיון השקיעו בעלי הרישיון כספים רבים במקרקעין, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על הציפייה הלגיטימית שלהם (ר': ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו)).

הנתבע לא עמד בנטל להוכיח כי רשות השימוש שניתנה לו, לטענתו, מכח שתיקת בעלי הדירות, הינה רשות שימוש בלתי הדירה.

ראשית, יש לזכור כי המדובר במקרה דנן ברשות שימוש הנלמדת מכלל, ללא הסכמה פוזיטיבית. הסכמה מכלל שכוז, מעצם טבעה, איננה יכולה לקבל תוקף קנייני וגם לא קונקרטיות, תמורה וצפייה לגיטימית לשם קבלת תוקף בלתי הדירה.

שנית, לא הוכח כי הנתבע ביצע השקעות או הוציא כספים רבים להכשרת השימוש בחצר - לגרסת הנתבע המדובר במחסן שנבנה לפני עשרות שנים במצבו כפי שהוא, למעט החלפת גג אסבסט בגג פח (עמוד 11 שורות 5-6). גם מר יצחק אלגזי מאשר כי הנתבע לא בנה את המחסן ואך עשה תיקון בו (עמוד 9 שורה 30).

שלישית, לא הוכחה תמורה לבעלי הדירות בגין השימוש במחסן. למעשה, כלל לא נטען כי ניתנה תמורה בהקשר זה אלא אך כי המדובר היה בחלוקה פנימית בין בני המשפחה. ויודגש, גם בהקשר זה לא הובאה על ידי כל עדות של בני המשפחה, בעלי הזכויות בבית על פי החלוקה הנתענת.

רביעית, לא הוכחה צפייה לגיטימית של הנתבע לכך שיוכל לעשות שימוש לצמיתות במחסן ללא כל תמורה, בוודאי לצורך השכרתו המסחרית לצד שלישי.

ויודגש, הנתבע מעורה באשר קורה בנוגע לחנות רק משנת 2007 (עמוד 10 שורות 10-11). משכך, העדות הרלבנטית היחידה מטעמו הינה עדות אביו – יצחק אלגזי, אולם, כאמור, על עדות זו קשה להסתמך, בוודאי לצורך הכרעה בזכויות קנייניות.

בנסיבות אלו לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי בידו זכות שימוש בלתי הדירה. אולם, התנהלות בעלי הדירות כאמור לעיל ושתיקתם לאורך השנים הקנו לנתבע רשות שימוש הדירה ולכך משמעויות כפי שיפורטו להלן.

אין טענתו החלופית של הנתבע בדבר קניית זכות זיקת הנאה מכח שנים יכולה לעמוד לו להגנה בהליך זה. סעיף 5 לחוק המקרקעין מגדיר "זיקת הנאה" כ- "שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו זכות להחזיק בהם". במקרה דנן המדובר בחזקה בפועל של הנתבע בשטח החצר ובינוי של מחסן על גבי שטח זה. פעולה זו, מעצם טיבה וטבעה, איננה יכולה לקבל ביטוי קנייני כ- "זיקת הנאה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 23/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

זאת ועוד. המדובר בסכסוך בנוגע לרכוש משותף בבית משותף על פי מסמכי רישום הבית המשותף. משכך, לא יכולה כלל להיווצר זכות קניינית מסוג "זיקת הנאה" כהגדרתה בחוק המקרקעין בנוגע לרכוש המשותף בבית, שהרי לכל בעלי הדירות בבית, לרבות הנתבע, זכות בעלות משותפת באותו רכוש משותף.

גם אין בידי לקבל את טענתו בדבר שימוש התובעים בזכותם הקניינית לרעה.

עקרון תום הלב אומנם חולש על כל תחומי המשפט, לרבות, במערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (2896/90 טרזקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454, ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זידה פ"ד לז (4) 737 ורע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נ' משה סלומון ואח' פד"י נח (1) 199). אולם, במקרה דנן לא מצאתי כל חוסר תום לב בהתנהלות התובעים או בסעדים המבוקשים על ידם.

השימוש אותו מבצע הנתבע ברכוש המשותף הינו, כאמור, שימוש ייחודי, מסחרי, מפריע ובלתי סביר. התובעים זכאים לדרוש החזרת מצב הרכוש המשותף לקדמותו ואין בדרישה זו, כשלעצמה, להוות התנהגות בחוסר תום לב או עמידה על זכויותיהם הקנייניות שלא כדין. אף אם ניתנה רשות שימוש הרי שזו לא היתה בלתי הדירה והתובעים זכאים להפסיקה, בכל עת. קבלת הטענה כי הפסקת רשות השימוש כמוה תמיד כשימוש לרעה בזכות או התנהלות בחוסר תום לב, משמעה מתן זכות שימוש בלתי הדירה מקום שזו לא ניתנה.

למעלה מכך, במקרה דנן גם לא שוכנעתי כי המדובר בתובענה שכל מטרתה לגרום נזק או אי נוחות לנתבע - מטרתה של התביעה להחזיר את הרכוש המשותף לידי בעלי הדירות כולם, לרווחתם המשותפת (ר' עדות קשי עמוד 8 שורות 7-11). כאמור לעיל, ממילא גם לא הוכחה צפייה לגיטימית של הנתבע להמשיך ולעשות שימוש לצמיתות במחסן הבנוי על הרכוש המשותף, אשר התעלמות ממנה עשויה להחשב כהתנהגות בחוסר תום לב.

אין נפקות ממשית לטענת הנתבע בדבר העדר סמכות הנציגות לנקיטת ההליכים דנן ואין צורך להיזקק לה שעה שבין התובעים מצויים גם בעלי דירות פרטניים, להם בודאי זכות תביעה. מכל מקום אעיר כי הנציגות מוסמכת לנהל את ההליך שבפני (ר' עש"א 11-01-36094 הופמן נ' נציגות ארלוזורוב 188 (פורסם בנבו)) וגם הוכחה בחירתה (נספח ו' לתצהיר מר קשי).

לאור כל האמור לעיל הרי שיש מקום להיעתר לתביעה למתן צו עשה לפיו ייגרס המחסן והנתבע יסלק את ידו מהחצר המשותפת.

אולם, לאור רשות השימוש שניתנה לנתבע מכללא על ידי בעלי הדירות כאמור לעיל, נכון יהיה לאפשר לנתבע זמן מספיק לביצוע פסק הדין, במיוחד בנסיבות בהן קיים שוכר במקום וכאשר התובעים גם ידעו על השכרתו של המחסן כמוזכר לעיל.

משכך, ובהעדר מידע בדבר מועד תום תקופת השכירות, נכון יהיה ליתן לנתבע שהות של 6 חודשים לביצוע חיובי העשה על פי פסק דין זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 23/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור רשות השימוש מכללא כאמור מוצא אני לנכון גם לדחות את התביעה לחיוב הנתבע בתשלום דמי שימוש ראויים בגין התקופה שעד מועד הגשת התביעה.

ראשית, לא עלה בידי התובעים להוכיח נזק ממון ישיר המזכה בפיצוי בגין הסגת גבול בהתאם להוראות סעיף 29 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. בהקשר זה לא הוכח כל הפסד ממון של מי מהנתבעים מן השימוש שבוצע על ידי הנתבע.

שנית, משהוכרה כאמור לעיל רשות שימוש בלתי הדירה שניתנה לנתבע על ידי בעלי הדירות ונדחתה טענת הנתבע בדבר היות רשות השימוש בלתי הדירה, בין היתר, לאור העובדה כי לא ניתנה כל תמורה בגין שימוש זה, לא ניתן להפוך עתה את היוצרות בדיעבד ולחייב במתן תמורה ראויה עבור שימוש הדיר שהוסכם מכללא לתיתו בחינם. חיוב בתשלום דמי שימוש יביא לתוצאה לפיה על אף שניתנה רשות שימוש חנם לנתבע וזו הופסקה על פי דרישה (בהגשת ההליך דנן), תהפוך רשות שימוש זו, רטרואקטיבית, לרשות שימוש בתשלום. הדבר יעקר מתוכן את בסיס חיוב הנתבע בסילוק ידו מן הרכוש המשותף.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה לצו עשה ומחייב את הנתבע להרוס את המחסן הבנוי על שטח החצר המסומנת בתשריט רישום הבית המשותף.

אני מחייב את הנתבע להשיב את מצב החצר לקדמותו ובכלל האמור לסלק כל פסולת בניה עקב הריסת המחסן, מטלטלין וכל ציוד שלו המצוי בשטח החצר, ולהחזיר את מצב החצר והקירות החיצוניים של הבית למצבם עובר להתקנת המחסן ובהתאם למסמכי רישום הבית המשותף.

אני אוסר על הנתבע לבצע כל בינוי בשטח החצר ו/או כל שימוש ייחודי בכל חלק משטח החצר אלא בהתאם להוראות הדין ועל פי הסכמת בעלי הדירות.

כפי שנקבע לעיל על הנתבע לקיים את חיובי העשה והמניעה כאמור בתוך 6 חודשים ממועד מתן פסק דין זה.

אני דוחה את התביעה לתשלום דמי שימוש בגין התקופה שעד למועד הגשת התביעה.

בנוסף לאמור לעיל אני מחייב את הנתבע להשיב לתובעים חלק יחסי באגרת התביעה בסך של 800 ₪ וכן סך של 4,680 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד.

לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות כאמור התחשבתי בכך שהתביעה נתקבלה בחלקה, התקיימו בתיק דיון מקדמי, דיון הוכחות וביקור במקום והוגשו סיכומים בכתב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 23/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ט אייר תשע"ג, 09 מאי 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב